



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1468/2017/CA1

///raná, 03 de noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"HERLEIN, JOSEFINA ELVIRA CONTRA INSSJP-PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986"**, Expte. N° FPA 1468/2017, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 40/42, contra la resolución de fs. 37/39 vta. que hace lugar a la acción de amparo interpuesta y condena a la accionada -Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados -INSJJP (PAMI)- a acordar a la amparista la prestación de kinesiología y fisioterapia domiciliaria, en base a la recomendación de su médico tratante y mientras lo requiera, en virtud de la enfermedad que padece "osteoporosis avanzada con médula ósea hipodensa", sin perjuicio de solicitarse la documental que se requiera, sin interrumpir la cobertura indicada, de conformidad a lo normado por el art. 43 de la Constitución Nacional y demás Tratados Internacionales aplicables; impone las costas a la demandada por resultar vencida, regula honorarios y tiene presente la reserva efectuada.

El recurso se concede a fs. 45, se contestan agravios a fs. 46/47 y quedan los autos en estado de resolver a fs. 52 vta.

II- a) Que, la apoderada de PAMI, manifiesta sucintamente que el fallo resulta arbitrario toda vez que no ha habido -por parte de la amparista- una tramitación previa de los pedidos pertinentes. Transcribe lo expresado por la magistrada a-quo y sostiene que no se han arrimado



elementos por la actora que permitan deducir incumplimiento de su parte y, por el contrario, sostiene que no se han cumplido los recaudos previstos para el otorgamiento de las prestaciones requeridas. Señala que se procedió a la cobertura de enfermería domiciliaria las 24 horas en favor de la actora y un tratamiento kinesiológico, que debe ser evaluado cada tres meses por falta de certeza en el diagnóstico. Indica que la carga de la prueba le fue impuesta a su parte vulnerando el derecho de defensa y finalmente, peticiona que se revoque la sentencia dictada respecto de la imposición de las costas a su parte.

b) Que la amparista responde a los agravios expresados, argumenta en torno a ellos, y solicita la confirmación del fallo recurrido, con costas.

III- Que, ante todo, cabe destacar que la accionante deduce acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -INSJJP (P.A.M.I.)- a los efectos de reclamar la cobertura integral de las prestaciones de kinesiología y fisioterapia conforme la indicación de sus médicos tratantes y en virtud de la enfermedad de "osteoporosis avanzada conjuntamente con artrosis generalizada y médula ósea hipodensa" que padece. Resalta que padece la enfermedad mencionada, que se caracteriza por una disminución de la densidad del tejido óseo y produce fragilidad exagerada en los huesos. Ello, sumado a su edad avanzada, motivó que se encuentre postrada con el consiguiente debilitamiento que se traduce en atrofia muscular. Por lo que le fue indicado el tratamiento para revertirla y, ante la solicitud efectuada a la obra social demandada mediante Carta Documento datada en fecha 15/02/2017, no obtuvo respuesta alguna.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1468/2017/CA1

Fundamenta la legitimación existente y la viabilidad de la vía procedimental intentada, y reclama la admisibilidad de la acción, con costas.

La magistrada de la instancia inferior, hizo lugar a la acción de amparo y contra dicha decisión se alza la accionada.

IV- a) En forma liminar, corresponde señalar que solo se abordarán aquellas cuestiones que, constituyendo agravio, hayan sido introducidas con un sólido planteo argumental y que, además, resulten conducentes para el tratamiento de la cuestión traída al Tribunal. Que, en tal sentido, se advierte que no se encuentra en juego la vía elegida, ni la afiliación, ni el padecimiento de la amparista. Asimismo debe remarcarse que resultan ajenas a la presente Litis las referencias brindadas por la demanda respecto a las prestaciones oportunamente otorgadas y que no son las aquí solicitadas.

b) Que, los agravios expresados remiten al análisis de la cuestión a resolver, esto es, si la cobertura de sesiones de kinesiología y fisioterapia requeridos deben prestarse inmediatamente por la demandada o merecen una nueva evaluación y tramitación por parte de la afiliada.

Más allá del limitado sustento probatorio, cabe concluir que en este caso no se han otorgado las específicas prestaciones de kinesiología y rehabilitación oportunamente solicitadas, ello sin perjuicio de lo alegado por la demandada respecto de la prueba que a su entender no fue producida por la accionante.

Al respecto, debe remarcarse que no se ha producido en autos ninguna prueba tendente a acreditar tal extremo y que la carga de hacerlo estaba en cabeza de la demandada.



Ello, en tanto la actora ha demostrado -a los efectos de la presente acción- que la única solución que resguarda adecuadamente su derecho a la salud es el tratamiento prescripto por su médico tratante.

Consta en autos que las prestaciones solicitadas fueron debidamente prescriptas por los profesionales tratantes, a fin de mejorar la calidad de vida de la paciente (cfr. fs. 1/2) y el reclamo fehaciente para que se le brinde la cobertura necesaria, tal como consta en la nota del 26 de enero y la carta documento (cfr. fs. 3) de fecha 15 de febrero, ambas del corriente año.

En virtud de ello, se concluye que lo solicitado en el promocional se justifica como extremo imprescindible a los fines de procurar la rehabilitación y una mejor calidad de vida de la actora, y esta situación no ha podido ser desvirtuada con la argumentación -genérica- de la recurrente.

Cabe recordar que el reconocimiento constitucional del derecho a la vida y a la preservación de la salud, tal como ha sido entendida por la Organización Mundial de la Salud comprende el concepto integral de salud, referido al bienestar psicofísico, mental y social de la persona. A su vez es comprensivo del reconocimiento a una adecuada calidad de vida.

Debe señalarse también que la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1468/2017/CA1

Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 1.948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d) y Pactos de Derechos Humanos art. 4, numeral 1, 5, 19, 26.

No brindar una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz sería violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud de la afiliada, debiéndose, a su vez, ponderar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de garantizar ampliamente el derecho a la salud integral (cfr. sent. 11-6-98 "Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. v. Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires" y en sentido coincidente S. C. Mendoza, en LL. 1993-E-36) y el reconocimiento de la existencia del derecho constitucional a la preservación de la salud (cfr. C.S.J.N, in re "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásticas", "Fallos" 323:3229).

Que, este Tribunal ha expresado en causas análogas, que las vías administrativas previas pueden ser una elección para la actora cuando las circunstancias del caso las indiquen como más aptas para resolver el conflicto, pero de ninguna forma, constituyen hoy una exigencia legal a fin de interponer una pretensión de amparo, por atentar contra el principio de celeridad que debe imperar en toda acción de amparo.

Tal criterio ha sido sustentado por la Excma. C.S.J.N cuando sostuvo: "...Las particulares circunstancias que rodean al caso, por encontrarse en definitiva, comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud y a la vida indican que no resultaba



razonable ni fundado impedir la continuidad de un procedimiento cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas -entre las cuales era razonable incluir al amparo contemplado en el art. 43 C.N. y en la ley 8369 de la Provincia de Entre Ríos- y, evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional ("Fallos" 329:2179)..." (CS, 30/10/2007, "María, Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado provincial", "Fallos" M.2648.XLI).

Consecuentemente, se impone rechazar el recurso y confirmar en todas sus partes la resolución apelada.

V- a) En cuanto al agravio de la demandada en relación a las costas a su parte, cabe destacar que fue su accionar el que dio razón suficiente a la amparista para litigar, quien se vieron forzada a recurrir a los estrados judiciales, por lo que la fijación de las mismas en primera instancia a la demandada vencida ha sido un criterio acertado.

b) Que, las costas habidas en la presente instancia, al no existir motivo para apartarse del principio general previsto en el art. 14 de la ley 16.986, deben imponerse a la apelante vencida.

Por todo ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución atacada.

VI- Que, corresponde regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a la Dra. María Alejandra Piérola en la suma de Pesos Novecientos Setenta y Cinco (\$975,00), y los correspondientes al Dr. Joel A.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1468/2017/CA1

Clapier en la suma de Pesos Mil Doscientos (\$1200,00) a cada uno (art. 14, ley 21839, T.O. por ley 24432).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia recurrida.

Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 14, primera parte de la ley 16986).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a la Dra. María Alejandra Piérola en la suma de Pesos Novecientos Setenta y Cinco (\$975,00), y los correspondientes al Dr. Joel A. Clapier en la suma de Pesos Mil Doscientos (\$1200,00) a cada uno (art. 14, ley 21839, T.O. por ley 24432).

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

MATEO JOSE BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO
ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

